2024년 특허·상표
판례연구논문 공모전
우수논문집

Intellectual Property
Trial and Appeal Board

06

장려상

박 상 철

확인대상발명의 기재가 부적법하여 각하된 심결에 대한 취소소송의 심리 범위 등 개선 방안에 관한 고찰

판례연구 논문 요약서

판례번호	대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결
제 목	확인대상발명의 기재가 부적법하여 각하된 심결에 대한 취소소송의 심리 범위 등 개선 방안에 관한 고찰
요 약	대상판결에 따라 심리·판단하여 판결하면 오히려 절차 지연 등 분쟁의 일회적 해결에 문제가 발생할 수 있으므로, 각하심결에 대한 취소소송에서 (1) 법원의 심리 범위는 원고의 주장은 반드시 판단하고, 직권조사사항 역시 의심이 있는 경우 판단해야 한다. 결국 심리 범위는 심판의 적법요건 일반이 되어야 하고, 다만 심판의 본안 판단은 심결전치주의에 따라 제한됨. (2) 법원의 판결은 법원이 직권으로 각하 사유를 판단하는 경우 원고에게 보정의 기회를 실질적으로 줄 수 없는 이상 청구기각판결은 불가하고, 청구를 인용하여 심결을 취소한 후 특허심판원에서 판결의 기속력에 따라 재심리하는 것이 바람직함. (3) 소송 비용은 민사소송법 제98조에 따라 패소자 부담을 원칙으로 하되, 법원이 직권으로 각하 사유를 판단하는 경우에는 민사소송법 제99조 내지 제101조에 따라 원·피고의 이익과 책임을 고려하여 원·피고에게 배분시키면 됨.
필 요 성	대상판결은 각하심결에 대한 취소소송에서 법원의 심리 범위에 관하여 무제한설에 따름을 다시 확인하였고, 직권조사사항에 대하여 새로운 법리를 판시함. 그러나 대상판결에 따라 심리·판단 및 판결하는 경우 오히려 절차 지연 등 부작용이 발생하므로 이를 개선할 필요가 있음.
독 창 성	각하심결은 일사부재리 적용이 없어 보정 후 재심판청구하면 되므로 취소소송을 제기할 필요가 없어 관련 판결이나 논문 등을 찾아보기 어려움. 이에 각하심결에 대한 취소소송의 심리 범위, 판결, 소송 비용 부담에 관하여 새로운 개선 방안을 제시하고자 함.
파급효과	적극적 권리범위확인심판은 특허권 침해소송과 대비하여 특허심판원과 법원, 변리사와 변호사, 개인·중소기업과 대기업·해외기업 사이에서 대립하는 중요한 쟁점임. 복잡한 확인대상발명의 기재 요건으로 인하여 사실상 특허권 침해소송이 강제되어 분쟁의 예방이나 신속한 종결 효과를 가지는 권리범위확인심판의 고유한 가치가 몰각되지 않도록, 확인대상발명의 기재 요건에 대한 심리 절차 및 판단 방법의 명확화·객관화가 필요하고 일관된 적용이 시급함.

장 려 상

확인대상발명의 기재가 부적법하여 각하된 심결에 대한 취소소송의 심리 범위 등 개선 방안에 관한 고찰

대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결

목 차 / Contents

1. 서 론 ····· 266
2. 이 사건 판결의 경위 ····· 267
   가. 사건의 배경
   나. 특허심판원 심결의 요지 (2019당2660)
   다. 특허법원 판결의 요지 (2020허4969)
   라. 대법원 판결의 요지 (2021후10725)
3. 대법원 판결의 문제점에 관한 고찰 ··· 271
   가. 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 기재
   나. 대법원 판결의 검토
   다. 각하 심결에 대한 취소의 소 제기의 취지
   라. 대법원 판결의 문제점
4. 개선 방안에 관한 고찰 ····· 278
   가. 법원의 심리 범위
   나. 법원의 판결
   다. 소송 비용의 부담
5. 결 론 ····· 286

1 서론

적극적 권리범위확인심판은 특허권자 또는 전용실시권자가 특허발명을 실시하거나 실시한 적이 있는 이해관계인에게 확인대상발명과의 관계에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확인하기 위하여 특허심판원에 청구하는 심판을 말한다(특허법 제135조). 권리범위확인심판은 단순히 특허발명 자체의 기술적 범위인 '사실관계'를 확정하려는 것이 아니라, 그 기술적 범위를 기초로 하여 문제가 된 구체적인 실시 형태에 대하여 특허권의 효력이 미치는 범위인 '권리관계'의 확정을 목적으로 한다.

따라서 적극적 권리범위확인심판의 결과는 특허권 침해소송에서 가장 중요한 본안 요건과 밀접하게 관련되고, 이 때문에 권리범위확인심판 제도는 특허심판관이라는 지식재산 전문가에 의한 심도 있는 판단에 더하여 당사자간 분쟁의 예방이나 신속한 종결 효과라는 고유한 기능과 가치를 지닌다(대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결).

적극적 권리범위확인심판을 청구할 때 청구인은 특허발명과 대비할 수 있는 '확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면'[1]을 첨부해야 하는데(특허법 제140조 제3항), 이는 특허권 침해소송에서 원고가 다양한 방식으로 침해 제품의 실시 형태를 기재할 수 있는 것과는 중요한 차이점이다. 특허발명의 보호 범위는 원칙적으로 청구범위에 적혀있는 '문자적 표현'에 의하여 정해지는데(특허법 제97조), 권리범위확인심판은 직권주의가 적용되는 동시에 대세적인 일사부재리 효력이 발생하여 그 심리 및 심결에 보다 명확하고 객관적인 기준이 필요한 반면, 특허권 침해소송에서는 변론주의가 적용되고 당사자간 기판력만 발생하면 되기 때문에 이러한 차이가 생기는 것으로 보인다.

한편 적극적 권리범위확인심판의 적법요건 중 '확인대상발명의 기재 요건'을 만족하지 못하는 경우, 보정이 불가하다면 특허심판원은 본안 판단에 나아가지 않고 바로 각하 심결할 수 있다(특허법 제142조). 이 때 각하 심결은 일사부재리가 적용

1) 심판청구 취지의 일부를 구성하며, 원칙적으로 요지변경이 되지 아니하는 범위에서 보정이 가능하다. (특허법 제140조 제2항)

되지 않기 때문에(특허법 제163조 단서), 청구인은 확인대상발명을 보정하여 다시 심판청구할 수 있고[2], 따라서 각하 심결에 대해서는 일반적으로 청구인이 불복하지 않을 것이기 때문에 관련 쟁점의 판례나 논문 등을 찾기 어렵다.

이하에서는 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 기재가 부적법하여 각하된 심결에 대한 취소소송의 심리 범위 등에 관하여, 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결을 중심으로 살펴보고, 이를 개선하는 방안을 검토한다.

2 이 사건 판결의 경위

가 사건의 배경

이 사건 등록특허 제10-0847870호는 '광고 제공 시스템 및 그 방법'에 관한 것으로서, 일반적으로 온라인상에서 구현되는 영업 방법(Business Method)에 관한 것이다. 청구범위 제1항은 다음과 같다.

[청구항 1]

사용자 단말기로 광고를 제공하는 시스템에 있어서,

상기 사용자 단말기로 웹 페이지 및 기본 광고 컨텐츠를 제공하며,

상기 사용자 단말기에 의해 부가 광고 컨텐츠를 활성화하기 위한 상기 기본 광고 컨텐츠에 대한 사용자 액션에 반응하여 상기 부가 광고 컨텐츠를 상기 사용자 단말기로 제공하고,

상기 사용자 액션에 대한 액션 정보 - 상기 액션 정보는 상기 기본 광고 컨텐츠의 노출 /클릭 횟수 및 상기 부가 광고 컨텐츠의 노출/클릭 횟수를 포함함 - 를 수집하는_컨텐츠 제공 장치; 및

상기 기본 광고 컨텐츠와 상기 기본 광고 컨텐츠를 상기 컨텐츠 제공 장치로 제

2) 소 제기와 같이 청구 시기에 법률상 또는 사실상 제한이 있는 것도 아니다.

공하며, 상기 액션 정보를 기초로 상기 기본 광고 컨텐츠 및 상기 부가 광고 컨텐츠의 광고 제공자에 대한 각각의 과금을 수행하는 광고 제공 장치를 포함하는 광고 제공 시스템.

위 청구범위 제1항에 대하여, 원고(청구인, 개인)는 피고(피청구인, 대기업)를 상대로 2019. 8. 21. 특허심판원에 「확인대상발명의 설명서 및 도면에 기재된 '광고 제공 시스템'은 이 사건 특허발명 제1항의 권리범위에 속한다.」는 취지의 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 2020. 6. 22. 「1. 이 사건 심판청구를 각하한다. 2. 심판비용은 청구인이 부담한다.」라는 심결을 하였다(2019당2660).

이에 불복하여 원고는 2020. 7. 20. 특허법원에 위 각하 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 2021. 7. 9. 「1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다.」라는 판결을 하였다(2020허4969).

다시 불복하여 원고는 2021. 7. 23. 대법원에 상고하였고, 대법원은 2023. 12. 28. 「원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.」라는 판결을 하였다(2021후10725).

나 특허심판원 심결의 요지 (2019당2660)

특허심판원은 2020. 6. 22. "원고가 특정한 확인대상발명은 피고가 실시하는 발명과 동일하지 않다"는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하는 심결을 하였는데, 그렇게 판단한 근거는 다음과 같다.

원고는 확인대상발명을 다음과 같이 특정하였다. "PC(Personal Computer)로 부가 광고 컨텐츠를 제공하는 시스템에 있어서, PC로 웹 메인페이지 및 기본 광고 컨텐츠를 제공하며, PC 사용자의 기본 광고 컨텐츠에 대한 마우스 오버에 반응하여 부가 광고 컨텐츠를 PC로 제공한다"

여기서 사용된 용어 '기본 광고 컨텐츠' 및 '부가 광고 컨텐츠'는 이 사건 제1항 발명에 기재된 용어와 동일하게 대응되고, 따라서 그 구체적인 의미를 이 사

건 특허발명의 명세서를 참작하여 살펴본다.

그런데 이 사건 특허발명의 명세서를 살펴보면 '부가 광고 컨텐츠'는 필연적으로 '기본 광고 컨텐츠'의 광고 영역(위치)에 종속하여 그 영역을 벗어나지 못하고 '기본 광고 컨텐츠'의 전부 또는 일부 영역 위에(상에) 팝업 등의 형식으로 표시되는 것이다.

한편 피고의 실시주장발명은 웹 페이지의 일정 영역을 점유하는 '탭'이 있고 '탭' 영역에 마우스 오버하는 경우 '탭' 의 영역을 벗어나 별도의 배타적 영역에 '광고'가 게재되는 것이다.

그러므로 피고의 실시주장발명은 '탭'과 관련된 광고 컨텐츠가 '탭'[3]을 벗어난 영역을 점유하고 있는데 비해, 원고의 확인대상발명은 부가 광고 컨텐츠가 '기본 광고 컨텐츠' 영역 위를 점유하는 것으로 특정하였는 바, 이는 확인대상발명을 실시주장발명과 다르게 특정한 것이다.

다 특허법원 판결의 요지 (2020허4969)

위 심결에 대하여 원고는 「확인대상발명은, '부가 광고 컨텐츠'가 '기본 광고 컨텐츠' 영역 위만 점유하는 것이 아니라 벗어난 영역도 점유할 수 있기 때문에, 특허심판원의 "원고가 특정한 확인대상발명은 피고가 실시하는 발명과 동일하지 않다"는 판단은 위법하다」고 주장하면서 심결취소소송을 제기하였다.

그런데 특허법원은 2021. 7. 9. 원고가 청구한 「특허심판원의 "원고가 특정한 확인대상발명은 피고가 실시하는 발명과 동일하지 않다"는 판단이 위법하다」는 주장은 심리하지 않으면서, 직권으로 "원고가 특정한 확인대상발명은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다"는 이유로 이 사건 소를 기각하는 판결, 즉 이 사건 각하 심결을 유지하는 판결을 하였는데, 그렇게 판단한 근거는 다음과 같다.

원고가 특정한 확인대상발명 중 '기본 광고 컨텐츠', '부가 광고 컨텐츠', '과금

3) 확인대상발명의 '기본 광고 컨텐츠'에 대응하는 실시 구성이다.

부'에 관한 기술 구성은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 볼 수 없다.

한편 특허심판원은 구술심리에서 확인대상발명의 설명서에 기재된 위 용어의 의미가 불분명하여 확인대상발명을 구체적으로 특정하기 어렵다는 취지로 석명하였다.

그러므로 원고의 확인대상발명은 구체적으로 특정되지 않았고, 특허심판원은 이에 대하여 석명하였으므로, 이 사건 심결은 그 결론에서 정당하다.

라 대법원 판결의 요지 (2021후10725)

위 판결에 대하여 원고는 「권리범위확인심판의 '각하' 심결에 대한 취소소송에서는 원고의 소의 이익을 위하여 '당해' 심결의 실체적·절차적 위법이 인정되면 특별한 사정이 없는 한 심결은 취소되어야 한다」고 주장하면서 상고하였다.

한편 대법원[4]은 2년이 넘는 심리 끝에 2023. 12. 28. 원고의 위 상고 이유를 배척하는 듯한 판단을 하였는데, 근거는 다음과 같다.

심판은 특허심판원에서의 행정절차이고, 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로,

심결취소소송의 당사자는 심결에서 판단되지 않은 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송 단계에서 주장·증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

특히 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허 심판의 적법요건이므

4) 대법원은 원고가 특정한 확인대상발명 중 '기본 광고 컨텐츠', '부가 광고 컨텐츠', '과금부'에 관한 기술 구성은 설명서와 도면을 종합적으로 고려하면 어떠한 기술 구성과 의미를 나타내는지 파악하는데 어려움이 없어 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별됨에 지장이 없다는 이유로 파기환송하였다. 다만 이에 대한 구체적인 내용은 본 논문과 직접적인 관련이 없어 생략하고, 추가적 쟁점 사항이 있으므로 별도의 논문으로 다룰 예정이다.

로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있는 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다.

따라서 원심이 이 사건 심결에서 판단되지 않은 사항인 확인대상발명의 특정 여부를 직권으로 심리·판단한 것에는 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하는 등의 잘못이 없다.

3 대법원 판결의 문제점에 관한 고찰

가 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 기재

적극적 권리범위확인심판에서 청구인(원고)이 기재한 '확인대상발명'이 심판의 적법요건으로서 판단되는 경우는 다음과 같다.

(1) 청구(확인대상발명)의 특정 (대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결)

특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라(청구원인의 특정), 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(청구취지의 특정). 만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원은 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등 조치를 취해야 하며, 그럼에도 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 한다.

(2) 확인의 이익 (대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결)

특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에

속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다. 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다.

즉 원고가 기재한 확인대상발명은 '청구취지의 특정', '청구원인의 특정', '확인의 이익' 요건 모두 적법성 판단을 받아야 한다. 반면 특허권 침해소송에서는 청구의 대상이 되는 침해 제품의 특정[5]과 관련하여 "사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다"고 판시하여 '청구취지의 특정' 요건만 만족하면 되고(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결), 나머지 사유로는 청구가 각하되지 않는다.[6] 즉 본안심리 및 판결해도 문제가 없다.

결국 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 기재가 적법하려면, 위 3가지 요건을 '모두' 만족해야 하고 어느 하나라도 만족하지 못하는 경우에는 여전히 부적법해진다. 이는 무효심판을 기각하려면 해당되는 무효사유를 '모두' 탄핵해야 하고 어느 하나라도 인정되는 경우에는 여전히 무효인 것과 유사하다.

따라서 확인대상발명의 기재에 관한 적법성 판단은 위 3가지 요건이 일체로서 이루어져야 하는 것은 아닌지 문제된다.

5) 심지어 모델명 등으로 실시 제품을 특정한 것도 적법하다고 하였다. (대법원 2019. 1. 31.자 2016마5698 결정)

6) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무, 제4판, 박영사, 2019, 421

나 대법원 판결의 검토

(1) 무제한설

대법원은, 심결취소소송에서 법원의 심리 범위에 관하여 그동안 일관되게 판시하였던 '무제한설' 법리를 다시 한 번 확인하였다. 즉 당사자가 심결취소소송 단계에서 (새롭게) 주장·증명하였다면 법원은 제한없이 이를 심리·판단할 수 있다는 것이다.

(2) 직권심리·판단

여기에 더하여 대법원은, '심판의 적법요건'은 특허심판원이나 법원 모두 직권조사사항이기 때문에 당사자의 주장·증명이 없더라도 의심이 있는 경우 직권으로 심리·판단하여야 한다고 판시하였다. 이 역시 직권조사사항에 관한 민사소송요건의 판단 법리와 다르지 않은 것으로 보인다.

(3) 심리·판단의 순위

한편 위 '심판의 적법요건' 판시에 대하여, 대법원이 확인대상발명의 기재와 관련하여 '확인의 이익' 판단보다 '청구(확인대상발명)의 특정' 판단을 먼저 해야 한다고 순위를 특별히 정한 것은 아니라고 할 것이다. 왜냐하면 확인대상발명의 기재는 심판의 적법요건으로, 본안 판단의 전제로서 모든 적법요건이 일체로 판단되어야 하기 때문이다. 따라서 위와 같은 적법성 판단에 순위를 두는 것은 부당한데, 이는 후술한다.

다만 대법원은 말미에 "따라서 이 사건 확인대상발명이 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 볼 수 있으므로, 원심으로서는 나아가 이 사건 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있는지를 살핀 다음, 구체적으로 특정되어 있다면 이 사건 심판청구가 피고가 실시하고 있지 않은 확인대상발명을 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판청구인지 여부를 살펴 이 사건 심결의 당부를 판단하였어

야 한다."고 판시하였는데, 이는 판단의 순위나 순서를 정했다기보다는 각하 심결에 대한 취소소송에서 법원의 심리 범위를 '심판의 적법성 판단'에 한정하는 취지로 볼 수 있을 것이다.[7)]

(4) 미판단

한편 대법원은, 원고의 다른 상고이유 「확인대상발명이 구체적으로 특정되지 않았다는 원심의 직권 판단이 설령 맞다고 하더라도, 특허심판원은 이를 심리한 바가 없으므로 원고에게 확인대상발명을 보정할 기회를 주었다고 볼 수 없다.」는 주장에 대해서는 파기 환송을 이유로 아무런 판단을 하지 않았다.

다 각하 심결에 대한 취소의 소 제기의 취지

(1) 일사부재리 부적용

문제는 원고가 심결취소소송을 제기한 이유로부터 발생한다. 원고는 '청구취지의 특정', '청구원인의 특정', '확인의 이익' 요건 중 어느 것이든 무관하게 결국 확인대상발명의 기재가 부적법하다(적법요건에 반한다)는 이유로 각하 심결을 받았는데 각하 심결에는 일사부재리가 적용되지 않으므로[8)], 만약 특허심판원의 판단이 적법하다면, 그 판단대로 확인대상발명을 보정하여 다시 심판청구를 하면 그만이다.

7) 이와 유사하게, 심판청구를 각하한 심결이 위법하여 취소되어야 하는 경우 특허법원은 판결로써 당해 심결을 취소할 수 있을 뿐 직접 심판청구의 본안 판단은 할 수 없다고 한 하급심 판결로 특허법원 2006. 11. 17. 선고 2006허1513 판결(확정)이 있다. 또한 최근 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결에서 각하 심결에 대한 취소소송의 심리 범위에 관하여, 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않고 법원은 이를 판단할 수도 없다고 하였다. 민사소송법 제418조(필수적 환송) 역시 소가 부적법하다고 각하한 제1심 판결을 취소하는 경우에 항소법원은 사건을 원칙적으로 제1심 법원에 환송하여야 한다고 규정하고 있다.

8) 확정된 심결이 심판청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다. 심판청구권 보장은 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다. (대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결)

(2) 재청구의 불가능

그러나 특허심판원의 판단이 위법한 경우에는, 그 판단대로 확인대상발명을 보정하게 되면 원고로서는 애초부터 권리범위에 속하지 않는 확인대상발명을 기재하여 청구하게 되는 모순이 발생하게 되는데, 그렇다고 원래대로 확인대상발명을 보정하지 않고 다시 청구하게 되면 원고의 적법한 주장에도 불구하고 특허심판원은 전 심결례에 구속되어 다시 각하 심결할 가능성이 크다.

(3) 침해소송의 강제

그렇게 되면 원고는 결국 당사자간 분쟁의 예방이나 신속한 종결 효과를 가지는 권리범위확인심판을 더이상 청구할 수 없고, 본안 판단을 받기 위해서 사실상 특허권 침해소송이 강제되는 불합리가 초래된다. 이러한 강제는 특히 자본력이 부족한 개인이나 중소기업 특허권자에게 부당하다.

(4) 심결취소소송의 제기

따라서 원고로서는, 각하 심결에는 일사부재리가 적용되지 않음에도 불구하고, 특허심판원의 위법한 판단을 시정하기 위하여 심결취소소송을 제기할 합리적인 필요가 생기게 되고, 이를 특허법원에서 심리·판단하여 청구가 인용되면, 취소 환송 후 특허심판원에서 재심리시 당해 특허법원 판단에 기속력을 발생시킬 수 있으므로(특허법 제189조 제3항), 원 심판에서 본안 판단에 나아갈 수 있다는 구체적인 이익 또한 생기게 되는 것이다.

다 대법원 판결의 문제점

(1) '본안 심결'에 관한 법리

심결취소소송에서 법원의 심리 범위에 관한 법리는 대부분 특허심판원의 '본안 심결'을 불복한 사건에서 나온 것이다.

이 사건에서도 대법원이 판시한 내용은, 심결취소소송 단계에서 법원은 ① 당사자의 주장이 있다면 무제한설[9]에 따라 심리·판단할 수 있고, ② 당사자의

주장이 없더라도 심판의 적법요건은 직권조사사항이므로 심리·판단할 수 있다는 것이다.

그런데 대법원은 ③ 당사자의 주장이 있는데도 불구하고[10] 이를 심리·판단하지 않는 경우, 즉 당사자의 주장을 배제하고 직권으로 다른 사항만을 심리·판단하는 경우에 대해서는 아무런 언급이 없다.

(2) '무제한설'의 취지

'무제한설'은 일반 항고소송과 달리 심결취소소송은 특허법 제186조 제6항 규정과 충돌하기 때문에 문제되는데, 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결에서 "당사자가 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송 단계에서 새롭게 주장하거나 증거를 제출할 수 있고, 법원도 이를 채택하여 판결의 기초로 삼을 수 있다"고 판시하면서, 그 이유로 "이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다"라고 하여 인정된 법리이다.

또한 항고소송이라는 본질적 특징 외에 어차피 무효로 될 특허라면 '제한설'에 따라 무효시기를 늦출 것이 아니라 조속하게 결론을 내릴 수 있도록 하여 소송경제와 국민 편익에 기여한다는 점도 '무제한설'의 근거가 되었다(특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무, 제4판, 박영사, 2019, 110-115).

즉 심결취소소송에서 '무제한설'이 인정되는 근본적인 취지는 해당 심리·판단으로 인하여 분쟁이 신속하고 종국적으로 해결되기 때문이다.

(3) 대법원이 간과한 점

이 사건에서 대법원의 판단은, 각하 심결에 대한 특수성과 심판의 요건별 차이를 고려하지 않은 것이다. 즉 당사자의 주장이 있는데도 불구하고 이를 배제하고 직권으로 다른 사항만을 심리·판단하는 판결이 가능한 것은, 그 다른 사항에 대한 판단만으로 분쟁이 종국적으로 해결되는 경우에 그렇다는 것이지, 언제나 그런 것은 아니다.

9) 무제한설에 따르더라도, 변론주의 원칙상 당사자가 소송에서 주장하지 않은 사항은 심리·판단할 의무가 없다. (정상조·박성수, 특허법 주해 II, 박영사, 2010, 809-811)

10) 처분권주의 또는 변론주의는 민사소송의 대원칙이다.

예컨대 신규성 위반이든 진보성 위반이든 결국 특허가 무효가 된다면, 당사자의 신규성 위반 주장을 배제하고 법원이 진보성 위반만을 판단해도 아무런 문제가 없다. 무효심판의 인용은 하나의 무효 사유라도 인정되면 그만이기 때문이다.

그러나 신규성도 있고 진보성도 있어 특허가 무효가 아닌 경우에는, 당사자의 신규성 위반 주장을 배제하고 법원이 진보성 위반만을 판단할 수는 없다. 무효심판의 기각은 모든 무효 사유에 대한 주장이 탄핵되어야 하기 때문이다.

따라서 심결취소소송에서 법원의 심리 범위에 대한 무제한설이나 직권조사사항의 법리는, 법원이 소송 단계에서 '어떤 사항에 대하여 심리·판단을 할 수 있는지'에 관한 것일 뿐, '오로지 어떤 사항만을 심리·판단해도 되는지'와는 별개의 문제이다. 대법원은 이를 간과하였다.

(4) 확인대상발명 기재 요건의 경우

심판의 적법요건 중 확인대상발명의 기재 요건은 특허심판원이나 법원에서 일체로 판단되어야 한다. 본안 심리 및 판단의 전제 조건이기 때문이다.

즉 확인대상발명의 기재는 '청구취지의 특정', '청구원인의 특정', '확인의 이익' 요건을 모두 통과하여야 본안 심리에 나아갈 수 있는데, 특허심판원에서 심결 이유로 지적된 사유를 법원에서 판단하지 않으면 원고로서는 여전히 확인대상발명을 보정하여 다시 심판청구할 수가 없게 된다. 따라서 법원에서 원고의 주장을 배제하고 직권으로 다른 사유만을 심리·판단하여 판결한다면 그 다른 사유가 옳고 그름과는 무관하게[11], 분쟁이 종국적으로 해결되기는커녕 심각한 절차 지연의 폐해가 발생하고 분쟁 전체의 일체적인 처리를 방해하게 된다.[12]

(5) 대법원 판결의 문제점

그렇다면 이 사건에서 법원이 원고가 주장한 확인대상발명의 기재 요건('확인의 이익')은 판단하지 않으면서, 직권으로 다른 확인대상발명의 기재 요건('청구

11) 법원의 직권 판단이 옳다면 원고는 그것도 반영하여 확인대상발명을 보정하면 된다.

12) 이러한 부작용은 아이러니하게도 '무제한설'이 '제한설'을 비판하는 가장 강력한 논거였다. (특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무, 제4판, 박영사, 2019, 112)

의 특정')만을 판단하여 청구를 기각하였는데, 대법원이 이를 그대로 지지한 것은 무제한설의 취지에 반하며, 처분권주의 또는 변론주의에도 위반된다고 생각되므로 타당하지 않다.

한편 대법원이 판단하지는 않았지만, 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 기재가 부적법하다는 것을 이유로 청구를 각하하기 위해서는 그 전에 원고에게 보정의 기회를 부여하여야 하는데, 특허법원은 속심이 아니고 1심이므로 원고에게 보정의 기회를 부여할 수 없다는 점도 문제된다.

또한 이 사건에서 법원은 소송 비용을 원고에게 부담시켰는데, 원고는 결국 청구한 주장에 대한 판단도 받지 못하면서 소송 비용만 부담하는 결과가 된 것도 문제된다.

다만 이러한 추가적인 문제는 결국 원고가 청구한 주장을 심결취소소송에서 법원이 판단하지 않았기 때문에 발생한 것이다. 이하에서는 개선 방안에 대하여 검토한다.

4 개선 방안에 관한 고찰

애초에 심결의 각하 사유가 적법하다면 심결취소소송을 제기할 필요가 없었던 원고는 청구한 주장에 대한 기속력을 얻기 위하여 이 사건 소를 제기한 것인데, 법원은 이에 대한 심리·판단을 하지 않으면서, 원고는 원하는 법적 결과를 얻지 못하였을 뿐만 아니라 절차는 현저하게 지연되고 소송 비용까지 부담하는 예상치 못한 결과에 이르렀다. 게다가 법원이 심리·판단한 사항만으로는 분쟁이 해결되지 않음은 물론이다.

이러한 경우, 원고가 결국 소 각하 판결의 위험이 낮은 특허권 침해소송을 검토할 수 밖에 없는 상황은 부당하다. 이를 해결하기 위하여, 각하 심결에 대한 취소소송에서 법원의 심리 범위 등에 대한 개선 방안을 검토한다.

가 법원의 심리 범위

(1) 원고가 청구한 주장에 대한 심리·판단 의무

무제한설의 취지는 소송경제와 분쟁의 일회적 해결이다. 따라서 법원은 이러한 취지에 맞게 심리·판단하면 된다.

상기한 바와 같이 확인대상발명의 기재는 원고의 입장에서는 하나의 사실적 표현임에도 법원의 입장에서는 '청구취지의 특정', '청구원인의 특정', '확인의 이익'이라는 상이한 법적 요건으로 인식된다. 그러나 분쟁을 궁극적으로 해결하기 위해서는 위 3가지 요건은 일체로 판단되어야 한다. 그래야만 그 판단에 따라 확인대상발명을 보정하여 본안 판단을 받을 수 있기 때문이다. 이는 민사소송에서 법원이 본안 판단을 하는 경우 소송요건을 전부 만족한다는 판단이 전제되는 것과 마찬가지이다.

즉 소송요건 판단은 본안 판단 대비 선순위성 및 일체성을 가진다. 환송판결의 기속력과 관련한 대법원 2012. 3. 29. 선고 2011다106136 판결에서 "따라서 환송판결이 위에서 본 바와 같이 구 특조법에 의하여 경료된 등기의 추정력이 번복되는 경우인지 여부에 대해서만 판단하였다고 하더라도, 그 판단은 원고가 소외 1 등 또는 그 상속인에 대하여 명의신탁 해지에 따른 이전등기청구권을 가지고 이를 피보전채권으로 하여 소외 1 등 또는 그 상속인을 대위할 수 있어 소송요건을 구비하였다는 판단을 당연한 논리적 전제로 하고 있다고 할 것이므로, 환송판결의 기속력은 원고의 이 사건 청구가 그와 같이 소송요건을 구비한 적법한 것이라는 판단에 대하여도 미친다."고 판시한 것은, 소송요건 판단은 일체로서 본안 판단의 전제라는 의미이다.

각하 심결에 대한 심결취소소송의 소송물로서 '심판의 적법요건'은, 순서나 개수가 중요한 것이 아니고 원고의 주장사항이든 법원의 직권조사사항이든 쟁점 사항이 하나라도 심리·판단되지 않으면 결국 심판에서 원고는 다시 본안 심결을 받을 수 없게 되므로 일체로서 판단되어야 하고, 이는 쟁점 사항 중 하나만 판단되어도 유효한 판결이 가능할 수 있는 '심판의 본안요건'과는 구별되는

점이다. 따라서 처분권주의 또는 변론주의 하에서, 당사자가 주장하는 사항을 법원이 판단하지 않아도 되는 경우는 직권으로 판단한 판결에 유효한 효력이 있고 분쟁의 일회적 해결에 도움을 주는 경우뿐이다.

결론적으로 원고의 심판청구권을 실현하기 위해서는 심판의 적법요건을 '모두' 만족해야 하고, 확인대상발명의 기재는 보정의 방법으로 그 부적법이 충분히 해소될 수 있다. 그렇다면 확인대상발명의 기재 요건에 관하여 원고가 청구한 주장은 심판의 적법요건을 궁극적으로 해결하는데 필수적이므로, 법원은 이를 반드시 판단할 의무가 있다.

(2) 직권조사사항에 대한 심리·판단 의무

상기한 바와 같이 확인대상발명의 기재 요건은 일체로 판단되어야 하므로, 법원은 분쟁의 일회적 해결을 위하여 의심이 있을 때는 직권조사사항에 대하여도 판단할 의무가 있다. 무제한설은 심결취소소송을 담당하는 법원을 마치 항소심적 지위에 있게 하는데, 항소심은 속심이므로 직권조사사항을 포함하여 불복의 범위에서 사건을 전부 재심리하기 때문이다.

대법원 또한 "심판의 적법요건은 직권조사사항이고 의심이 있을 때는 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항"이라고 판시하고 있으므로, 법원은 심판의 적법요건에 의심이 있는 경우 반드시 판단할 의무가 있다.

(3) 소 결

그러므로 각하 심결에 대한 취소소송에서 법원의 심리 범위는 원고가 청구한 주장을 포함한 '각하 심결에 대한 위법성' 일반, 즉 '심판의 적법요건' 일반이 된다.[13)]

원고의 심판청구권이 보장되려면 모든 적법요건의 판단이 전제되기 때문에, 주장되거나 의심되는 심판의 적법요건은 심결취소소송 단계에서 일체로 판단되어야 하고, 이렇게 하는 것이 법원의 심리 범위에 무제한설을 취하는 목적인 소송경제, 분쟁의 일회적 해결에 부합한다.

다만 특허법 제186조 제6항에 따라 '심판의 본안 판단'은 제한된다.

13) 다만 당사자가 명백하게 주장하지 않은 것은 판단할 필요가 없다.

나 법원의 판결

(1) 청구기각판결

법원이 청구기각판결을 할 수 있는 경우는 원고가 청구한 주장이 인정되지 않는 경우, 즉 각하 심결에서 특허심판원의 판단이 정당한 경우뿐이다.

한편 법원이 직권으로 각하 사유를 심리·판단한 경우에는 청구기각판결을 할 수 없다고 보아야 한다.

최근 대법원은 일관되게 심판이나 소송의 적법요건에 흠결이 있는 경우, 「심판청구인이나 원고에게 ① 실질적인 보정의 기회를 부여하여야 하고 ② 새로운 사유가 생기면 새로운 보정의 기회를 다시 부여하여야 하며 ③ 만약 보정 요구에 대하여 불충분하게 보정하였다면 오해가 없도록 보다 상세하게 보정의 취지를 풀어 설명하여야 한다」고 계속하여 파기 환송하고 있다.[14] 원고의 청구를 쉽게 각하하는 것은 본안 판단을 받기 위하여 노력한 원고에게 예상치 못한 피해를 주거나 원고의 청구권을 농락하는 것이 되기 때문에 당연하고 타당한 판결이다.

따라서 심판의 적법요건에 흠결이 있으면, 보정이 불가능한 것이 아닌 한, 특허심판원이나 법원은 이를 구체적으로 석명하여 보정의 기회를 주어야 한다. 다만 형식적으로는 보정의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 예외적으로 보정명령 없이 청구를 각하하더라도 이를 위법하다 할 수는 없다.[15]

그런데 심결취소소송은 1심이지 심결에 대한 속심이 아니므로, 법원은 특허심판원과는 달리 확인대상발명의 기재가 적법하지 않은 경우 원고에게 보정의 기회를 부여할 수 없다. 대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결에서도 "(가)호 발명의 설명서 및 도면은 특허심판절차에서만 보정할 수 있을 뿐 원심에

14) 대법원 2020. 11. 12. 선고 2017후1779 판결 [거절결정(상)]
대법원 2021. 3. 11.자 2020마7755 결정 [상고장각하명령에 대한 재항고]
대법원 2024. 1. 4. 선고 2023다282040 판결 [임금]

15) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결

서 보정할 수 없으므로 이 사건에 대하여 이 법원이 직접 판결하기로 하는바, 앞서 본 바와 같이 특허심판원이 1999. 3. 30. 98당1506호 사건에 대하여 한 심결은 위법하므로 이를 취소하기로 한다"고 판시하였다.

따라서 심판의 적법요건이 법원의 직권조사사항이라고 하더라도, 법원은 특허심판원이 판단하지 않은 새로운 각하 사유를 들어 바로 청구를 기각할 수는 없다. 새로운 각하 사유를 들려면 그 사유를 심리하고 보정의 기회를 다시 부여해야 하는데 법원은 그럴 수 없기 때문이다. 그렇다면 법원은 직권으로 판단한 새로운 각하 사유가 특허심판원에서의 각하 사유와 서로 다르다면, 특허심판원에서 원고에게 그 새로운 각하 사유까지를 포괄하여 보정의 기회를 실질적으로 부여하였는지 여부를 더욱 신중하게 판단해야 한다. 그런데 확인대상발명의 기재 요건인 '청구취지의 특정', '청구원인의 특정', '확인의 이익'에 대한 심리는 구체적인 판단 과정이 상이하기 때문에, 특허심판원에서 이들 상이한 요건에 관하여 실질적으로 동시에 보정의 기회가 주어졌다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건과 같이 특허심판원에서 '확인의 이익'을 심리하면서 한 보정 명령을, 법원이 판단한 '청구취지의 특정'을 심리하면서 한 보정 명령이라고까지 유추 적용할 수는 없다. 더욱이 특허심판원에서 한 '확인의 이익'의 판단이 적법하지 않은 경우는 더욱 그렇다. 원고는 부적법한 보정 명령에 따를 수는 없기 때문이다.

이와 별개로, 법원이 직권으로 새로운 각하 사유만을 심리·판단하여 청구기각판결을 하는 경우, 그 판결에 어떠한 법적 효력이 발생하는지 의문이다. 심결취소소송에서 청구를 기각하면 원심결이 그대로 확정되어 일사부재리 효력이 발생해야 하는데(특허법 제163조 본문), 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 일사부재리 효력이 발생하지 않기 때문이다(특허법 제163조 단서). 그렇다면 원고에게 각하 심결을 취소할 필요와 이익이 인정되는 이 사건에서, 결국 법원의 청구기각판결은 실질적으로 특허심판원의 잘못을 바로잡지 못하면서 원고에게 무용한 심판·소송을 반복하게 함으로써 원고의 권리 구제를 원천적으로 봉쇄하는 것과 다름없어 부당하다.

또한, 단순히 결론이 같다고 청구를 기각하는 것은 원칙적으로 사건을 전부 재심리하는 항소심[16]에서 가능한 행위이고, 무제한설에 의하더라도 심결취소소

송을 담당하는 법원은 직권으로 판단한 판결에 유효한 효력이 있고 분쟁의 일회적 해결에 도움을 주는 경우에 한해서만 가능하다고 볼 것이다.

이처럼 권리범위확인심판의 각하 심결에 대한 심결취소소송에서는 ① 법원에서 원고에게 보정의 기회를 줄 수 없고 ② 판결에 법적 효력이 없거나 분쟁의 일회적 해결에 반할 수 있기 때문에, 법원이 새로운 각하 사유로 청구를 기각하는 것은 제한되어야 한다.

(2) 청구인용판결

따라서 원고가 청구한 주장이 인정되지 않는 경우를 제외하고는 모두 청구인용판결을 하여야 한다.

심결이 취소되어 특허심판원으로 환송되면, 법원 판단의 기속력에 따라 심판의 적법요건을 재심리하면 된다. 이것이 소송경제 및 분쟁의 일회적 해결에 도움이 된다.

다만 심판의 적법요건 흠결로 청구가 인용된 경우, 이는 결국 원고(청구인)의 책임일 수 있는데, 소송 비용을 누구에게 부담시킬 것인가 문제된다.

다 소송 비용의 부담

(1) 민사소송법 규정

위와 같이 원고의 청구를 인용하는 경우 소송 비용 부담을 어떻게 할 것인지 검토한다. 소송 비용에 관한 민사소송법 규정은 아래와 같다.

제98조(소송비용부담의 원칙) 소송비용은 패소한 당사자가 부담한다.

제99조(원칙에 대한 예외) 법원은 사정에 따라 승소한 당사자로 하여금 그 권리를 늘리거나 지키는 데 필요하지 아니한 행위로 말미암은 소송비용 또는 상대방의 권리를 늘리거나 지키는 데 필요한 행위로 말미암은 소송비용

16) 민사소송법 제414조 제2항에서 "제1심 판결의 이유가 정당하지 아니한 경우에도 다른 이유에 따라 그 판결이 정당하다고 인정되는 때에는 항소를 기각하여야 한다."고 규정한 것은 민사소송의 항소심에서는 제1심의 속심으로서 제1심과 마찬가지로 모든 실체적·절차적 권리가 보호되기 때문이다.

의 전부나 일부를 부담하게 할 수 있다.

제100조(원칙에 대한 예외) 당사자가 적당한 시기에 공격이나 방어의 방법을 제출하지 아니하였거나, 기일이나 기간의 준수를 게을리 하였거나, 그 밖에 당사자가 책임져야 할 사유로 소송이 지연된 때에는 법원은 지연됨으로 말미암은 소송비용의 전부나 일부를 승소한 당사자에게 부담하게 할 수 있다.

제101조(일부패소의 경우) 일부패소의 경우에 당사자들이 부담할 소송비용은 법원이 정한다. 다만, 사정에 따라 한 쪽 당사자에게 소송비용의 전부를 부담하게 할 수 있다.

(2) 특허법원 판례

특허법원은, 권리범위확인심판의 본안 심결을 받고 권리자 측이 원고로 불복한 사안에서, 심판의 적법요건 흠결로 심결을 취소하는 경우, 원고의 청구를 인용하되 소송 비용은 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제99조에 의하여 확인대상발명을 제대로 기재하지 아니한 원고에게 부담시킨 사례가 있다.[17] 심판의 적법요건 흠결은 결국 원고의 책임이라는 의미에서는 일응 타당한 면이 있다.

(3) 소 결

그렇다면, 원고에게는 이 사건 소를 제기함으로써 위법한 각하 사유를 취소시켜 기속력을 얻을 합리적인 필요와 구체적인 이익이 있고, 피고로서도 실시 형태의 항변을 태만히 하여 분쟁을 지연시키는 등[18]의 책임이 있을 수 있기 때문

17) 특허법원 2005. 4. 21. 선고 2005허438 판결, 특허법원 2007. 6. 13. 선고 2006허8705 판결, 특허법원 2007. 9. 13. 선고 2007허456 판결 등. 그런데 이러한 예상치 못한 적법성 흠결로 인한 인용 판결에 불복하여 원고가 상고하는 경우 전부 승소한 자의 상고라는 이유로 바로 각하된다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후4038 판결). 특허법원의 적법성 흠결 판단이 옳은지에 대한 불복이 불가능하다는 점에서 기이하다.

18) 특허권 침해소송에서는 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무), 제132조(자료의 제출)와 같은 피고의 실시 형태를 규명할 수 있는 규정이 있는 반면, 적극적 권리범위확인심판에서는 해당 규정이 없어서 문제된다.
실제로 적극적 권리범위확인심판에서 '확인의 이익'을 심리·판단하는 경우, 판례가 설시한 '사실적 관점에서 동일해야 한다'는 조건을 악용하여 피고(피청구인)가 자신의 실시 형태에 대하여 단순히 원고의 확인대상발명을 실시하지 않는다고 부인만 하면서 적극적으로 항변하지 않고 사건을 지연시키는 경우가 많은데, 특허법원은 위 규정은 특허권 침해소송에서만 적용되는 것이라고 판시하면서 이러한 부당한 상황을 방치하고 있는 실정이다. (특허법원 2020. 11. 20. 선고 2020허1342 판결, 특허법원

에 소송 비용에 대하여 당사자의 특별한 사정이 종합적으로 고려되어야 한다. 법원은 다음과 같이 소송 비용에 대한 판결을 할 수 있다.

① 원고가 청구한 주장이 인정되지 않아 청구를 기각하는 경우, 민사소송법 제98조를 적용하여 패소한 원고에게 부담시킨다.

② 원고가 청구한 주장을 인정하여 청구를 인용하는 경우, 민사소송법 제98조를 적용하여 패소한 피고에게 부담시킨다.

③ 원고가 청구한 주장을 인정하면서도 직권으로 각하 사유를 판단하여 청구를 인용하는 경우, 민사소송법 제99조 내지 제101조를 적용하여 원·피고의 이익과 책임을 고려하여 원·피고에게 배분시키면 된다.

2023. 6. 8. 선고 2021허4171 판결, 특허법원 2023. 9. 21. 선고 2022허5355 판결 등)
그러나 적극적 권리범위확인심판에서 청구 취지의 일부로서 '확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면'을 요구하는 이유는 일반공중에 대세효를 가지는 일사부재리 때문이고(특허법 제163조), 이를 위하여 특허심판은 민사소송과는 달리 공익적 성격이 강한 '직권주의'가 적용되기 때문에(특허법 제159조 등), 위 규정의 존부와 상관없이 원래부터 특허심판원은 피고(피청구인)의 실시 형태에 관하여 실체적 진실에 부합하도록 적절하게 석명권 등을 행사할 수 있어야 하고 또 그래야 한다. 그렇지 않으면 제법 특허나 특히 이 사건과 같이 영업방법(BM) 특허의 경우, 일반적인 제품(물건)과는 달리 피고의 실시 형태에 대한 '사실적 증거'는 피고의 회사 또는 시스템 내부에만 존재하기 때문에, 적절한 심판 지휘가 없다면 애초에 적극적 권리범위확인심판은 청구 자체가 어렵게 되기 때문이다. 한편 변론주의에 적용되는 규정이 자백간주의 효력마저 배제되는 직권주의에는 적용될 수 없다는 특허법원의 판단은 개정된 법률에 대한 형식적인 반대해석으로서 쉽게 동의하기 어렵다.
또한 동일한 목적, 절차 및 효과를 가지는 소극적 권리범위확인심판에서는 '실시하고 있지 않은 발명'도 확인의 이익을 인정하는 것(대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결 등 다수)과의 형평성 측면에서도 맞지 않는다고 할 것이다.
적극적 권리범위확인심판에서 원고가 기재한 확인대상발명에 대하여, (특허권 침해소송에서와 같이) '심판청구의 취지'가 적법하게 특정된 이상 그것을 기준으로 본안 심리를 하여 청구 인용 또는 기각 심결을 하여도 (일사부재리와 같은) 아무런 문제가 없음에도 불구하고, 실시주장발명과 동일성이 인정되지 않는 경우 '확인의 이익'이 없다고 하여 본안 심리를 하지 않고 심판청구를 각하하는 이유는, 설령 권리범위에 속한다는 심결(인용 심결)이 확정된다고 하더라도 그 심결은 청구인이 특정한 발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피청구인이 실시하고 있는 발명에 대해서는 아무런 효력이 없기 때문인데(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결, 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결), 이러한 이유는 ① 소극적 권리범위확인심판에서도 마찬가지로 문제되므로 형평에 어긋나 부당할 뿐만 아니라, ② 특히 확인의 이익 요건 및 본안 요건(권리범위 속부) 판단이 동일한 내용인 경우, 예컨대 '구성요소 완비의 원칙'과 같이 어느 실시 구성요소가 존재하는지 존재하지 않는지 양 요건에서 동일한 내용으로 다투는 경우에는 구체적인 본안 심리를 통하여 해당 구성요소가 존재하는 것으로 인정하여 권리범위에 속한다는 인용심결을 한다면 당연히 실시 발명으로도 인정되어 심결의 효력이 미치기 때문에, 아무런 검토 없이 구체적인 심리도 하지 않고 위 판결을 추종하여 '확인의 이익'이 없다고 단정하여 곧바로 각하하는 것은 부당하다.

5 결 론

대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결은, 적극적 권리범위확인심판의 확인대상발명의 기재 요건이 부적법하여 각하된 심결에 대한 취소소송에서 법원의 심리 범위에 관하여 「법원은 당사자가 심결취소소송 단계에서 주장·증명하는 심결의 위법 사유는 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있고, 특히 심판의 적법요건에 대해서는 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있는 때에는 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다」라고 하여, 기존 무제한설에 따름을 다시 확인하였고, 더하여 직권조사사항에 관하여 새로운 법리를 판시하였다.

그러나 위 판결에 따라 법원에서 원고가 청구한 주장을 배제하고 직권으로 다른 사유만을 심리·판단하여 판결한다면 그 다른 사유가 옳고 그름과는 무관하게, 분쟁이 종국적으로 해결되기는커녕 심각한 절차 지연의 폐해가 발생하고 분쟁 전체의 일체적인 처리를 방해하게 된다.

왜냐하면 심판의 적법요건 중 확인대상발명의 기재 요건은 본안 판단의 전제 조건이므로 법원에서 일체로 판단되어야 하기 때문이다. 즉 확인대상발명의 기재는 '청구취지의 특정', '청구원인의 특정', '확인의 이익' 요건을 모두 통과하여야 비로소 본안 판단에 나아갈 수 있는데, 특허심판원에서 심결 이유로 지적된 사유를 법원에서 판단하지 않으면 원고는 여전히 확인대상발명을 보정하여 다시 심판청구할 수가 없게 된다.

애초에 특허심판원의 각하 사유가 적법하다면 심결취소소송을 제기할 필요가 없었던 원고는 청구한 주장에 대한 기속력을 얻기 위하여 이 사건 소를 제기한 것인데, 법원은 이에 대한 심리·판단을 하지 않으면서, 원고는 원하는 법적 효과(기속력)를 얻지 못하였을 뿐만 아니라 절차는 현저하게 지연되고 소송 비용까지 부담하는 예상치 못한 결과에 이르렀다. 게다가 특허법원이 심리·판단한 사항만으로는 분쟁이 해결이 되지 않음은 물론이다. 이러한 경우, 원고가 결국 소 각하 판결의 위험이 낮은 특허권 침해소송을 검토할 수 밖에 없는 상황은 부당하다.

이를 해결하기 위하여, 각하 심결에 대한 취소소송에서 법원의 심리 범위 등에 대한 개선 방안을 검토하여 보면,

(1) 법원의 심리 범위는 소송경제 및 분쟁의 일회적 해결을 위하여 원고가 청구한 주장은 반드시 판단하고, 직권조사사항 역시 의심이 있는 경우 판단하여야 한다. 결국 심리 범위는 원고가 청구한 주장을 포함한 각하 심결의 위법성 일반, 즉 심판의 적법요건 일반이 되어야 하고, 다만 심판의 본안 판단은 심결전치주의에 따라 제한된다.

(2) 법원의 판결은 법원이 직권으로 각하 사유를 판단하는 경우에 법원에서 원고에게 보정의 기회를 실질적으로 줄 수 없는 이상 소송경제 및 분쟁의 일회적 해결을 위하여 청구기각판결은 불가하고, 청구를 인용하여 심결을 취소한 후 특허심판원에서 판결의 기속력에 따라 재심리하는 것이 바람직하다.

(3) 소송 비용은 민사소송법 제98조에 따라 패소자 부담을 원칙으로 하되, 법원이 직권으로 각하 사유를 판단하는 경우에는 민사소송법 제99조 내지 제101조에 따라 원·피고의 이익과 책임을 고려하여 원·피고에게 배분시키면 된다.

적극적 권리범위확인심판은 특허권 침해소송과 대비하여 특허심판원과 법원, 변리사와 변호사, 개인·중소기업과 대기업·해외기업 사이에서 대립하는 중요한 쟁점이다. 이들 이해관계자는 사회·경제적으로 서로 입장차가 뚜렷하므로, 동일한 지식재산사건에 관한 지식(경험), 절차, 판단, 자본력 등이 달라 어느 절차를 선택하느냐에 따라 분쟁 상황이 예측 불가능해지거나 완전히 상이한 결과에 이를 수 있기 때문이다.

이를 해결하는 간명한 방안은, 권리범위확인심판을 침해소송에 흡수시키는 것이지만, 행정부와 법원의 권한 관계, 변리사와 변호사의 직무 관계, 개인·중소기업과 대기업·해외기업의 경제적 관계 등의 문제로 인하여 현실적으로 쉽지 않은 일이다. 게다가 권리범위확인심판은 분쟁의 예방이나 신속한 종결 효과라는 고유의 기능을 가지므로 제도가 유지될 실질적인 필요가 있다.

그런데 소송요건 흠결로 소가 각하되는 사례가 적은 특허권 침해소송과는 달리, 적극적 권리범위확인심판에서는 유독 '확인대상발명의 기재' 요건이 문제된

다. 특히 이 요건은 심판 단계 뿐만아니라 심결취소소송, 심지어 상고 단계에 이르기까지 언제든 예상치 못한 판단을 받을 위험이 있으므로 중요한 쟁점이다. 만약 상고 단계에 이르러 부적법 판단을 받는 경우[19], 그때까지 심판청구인이 진행한 수년 동안의 시간, 노력, 비용은 일거에 물거품이 될 수도 있다. 이는 적극적 권리범위확인심판의 신속·경제·전문적 효과라는 고유의 가치를 몰각시킬 수 있는 심각한 상황이라고 보여진다.

이 사건도 마찬가지로 2019년에 심판청구된 사건이 2024년 현재까지도 본안 판단에 조차 나아가지 못하고 있는 것은 안타까운 일이다. 특히 자본력이 부족한 개인이나 중소기업 특허권자에게는 더욱 그렇다.

최근 특허법, 부정경쟁방지법 등이 자주 개정되는데, 법 개정의 목적은 언제나 일반 개인이나 중소기업 특허권자를 보호한다는 취지라고 홍보된다. 그러나 국내 지식재산법률 시스템이 일반 개인이나 중소기업 특허권자를 실질적으로 보호하는 방향으로 나아가고 있는지는 다시 한 번 세심하게 살펴보아야 한다.

헌법 제27조 제1항은 ”모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다“고 규정한다. 따라서 지식재산권의 침해 요건을 다투는 적극적 권리범위확인심판청구 역시 특허심판원이나 법원은 쉽게 각하해서는 안 되고, 청구된 사건의 실체적 진실에 접근하기 위하여 본안 판단으로 나아가야 할 책무가 있다.

복잡한 확인대상발명의 기재 요건으로 인하여 적극적 권리범위확인심판이 예상치 못하게 각하되어, 분쟁의 예방이나 신속한 종결 효과를 가지는 권리범위확인심판의 고유한 가치가 몰각되지 않도록, 확인대상발명의 기재 요건에 대한 심리 절차 및 판단 방법의 명확화·객관화가 필요하고 이에 대한 일관된 적용이 시급하다고 할 것이다.

19) 상고 단계에 이르러 부적법 사유가 해소되는 경우도 마찬가지이다.

참 고 문 헌

1. 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산소송실무」, 제4판, 박영사, 2019
2. 특허심판원, 「2024 심판편람」, 제14판, 특허심판원 심판정책과, 2023
3. 조영선, 「특허법 3.0」, 제7판, 박영사, 2021
4. 임병웅, 「리담특허법」, 제23판, 한빛지적소유권센터, 2024
5. 차상육, 「특허침해소송실무」, 한국지식재산연구원, 2018
6. 한국특허법학회, 「특허판례연구」, 제3판, 박영사, 2017
7. 사법연수원, 「특허법 연구」, 사법연수원 출판부, 2015
8. 임병웅·윤선희, “권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정에 관한 소고”, 지식재산연구 제14권 제3호, 한국지식재산연구원, 2019